

1500322-88.2021.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... a absolvição dele de rigor.

Associação para o Tráfico (art. 35)

Para a comprovação da materialidade do crime de associação para o tráfico, é imprescindível demonstrar os seguintes elementos típicos: i) um ânimo associativo, ou seja, "ajuste prévio e um mínimo de organização", (STF. 1ª Turma. RHC 75.236/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence); ou seja, é necessário um "dolo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500322-88.2021.8.26.0622 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-88.2021.8.26.0622

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2330184/2021 - Delegacia de Polícia de Itararé, 21770626 - 1º Distrito Policial de Itararé, 2108/21/409 - 1º Distrito Policial de Itararé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Johnatan Samuel Apostólico e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

JOHNATAN SAMUEL APOSTOLICO e LIGIA APARECIDA ALMEIDA foram denunciados e estão processados como incurso: (i) no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006; e (ii) art. 35, "caput", também da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69, do CP), porque: i) guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, três tijolos de crack, pesando respectivamente 1.054,68g, 1.038,91g e 1.044,02, oito porções grandes de crack, com peso aproximado de 402,31g (peso líquido total de 3.431,11g de crack), 126 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 26,51g, um pote de vidro contendo 33,47 gramas de maconha, duas sementeiras contendo sementes de maconha, com peso líquido de 300,23g, duas porções de maconha, com peso líquido de

0,49g, três vasos com pés de maconha (medindo 85 cm, 73 cm e 37 cm) com peso líquido de 63,75g, um pé de maconha grande (1,25cm) com peso líquido de 1.251,93g, substâncias capazes de provocar dependência física e psíquica, conforme auto de exibição, apreensão e constatação provisória de fls.38/43 e laudos periciais de fls.130/133 e 140/153 e ii) ainda, desde data incerta e perdurando até o dia 04 de dezembro de 2021, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º e 34 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (fls. 166/169) que:

“Segundo o apurado, a Guarda Civil Municipal recebeu delação anônima narrando que o denunciado Johnatan fazia cultivo de pés de maconha em sua residência, localizada na Rua José Rolim Sobrinho, nº 704. Assim, em diligências no local, os agentes públicos foram recebidos pela denunciada Lígia, companheira de Johnatan, que confirmou a existência de drogas na casa. Johnatan não se fazia presente, mas, com autorização de Lígia, os guardas ingressaram no imóvel.

Inicialmente, os guardas apreenderam, no quintal, um pé de maconha grande.

Depois, dentro do imóvel, no quarto utilizado pelo casal, encontraram mais três pés de maconha, cultivados em uma estufa improvisada dentro do guarda-roupa, além de uma sementeira mesma droga.

Prosseguindo, no mesmo quarto os guardas localizaram três tijolos de crack e outras oito porções grandes da mesma droga, 126 porções de cocaína, um pote de vidro contendo outra planta de maconha e dois cigarros artesanais de maconha; além disso, apreenderam 01 balança de precisão (com resquícios de maconha), 750 microtubos novos e vazios (“eppendorf”), 01 canivete (com resquícios de maconha), 01 sistema de iluminação e ventilação para cultivo indoor de plantas, fabricado artesanalmente, utilizado no cultivo da maconha, 01 rolo de plástico transparente para embalagem de droga, 07 embalagens de papel de seda, aproximadamente 1.000 saquinhos plásticos, tipo “sacólés” (com resquícios de maconha), comumente utilizados para embalar drogas, conforme laudo pericial de fls. 134/139.

Por fim, os agentes públicos apreenderam 3 aparelhos celulares e R\$13,50 em dinheiro. Durante as diligências, o denunciado Johnatan compareceu ao local, ocasião em que confirmou a propriedade das drogas, sendo preso em flagrante juntamente com Lígia.”

A prisão em flagrante do réu JOHNATAN foi convertida em preventiva; tendo sido concedida liberdade provisória à ré LÍGIA com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Foi determinada a notificação dos acusados em 10 de janeiro de 2022 (fls. 170/171).

A ré LÍGIA foi notificada pessoalmente em 13 de janeiro de 2022 (fls. 217/218) e o réu JOHNATAN por vídeo-chamada em 17 de janeiro de 2021 (fl. 2020).

Foi apresentada defesa prévia (fl. 221).

A denúncia foi recebida 20 de janeiro de 2022 (fl. 228).

Em audiência em 26 de janeiro de 2022, foram ouvidas quatro testemunhas e interrogada a ré Lígia.

Em audiência em 10 de fevereiro de 2022, foi interrogado o réu, sendo que o Ministério Público requereu a juntada de relatório de investigação faltante.

Em alegações finais escritas, em que o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, com a condenação do réu Johnatan no crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e absolvição dos réus no tocante às demais imputações. A Defesa postulou a absolvição da ré Lígia, e o reconhecimento da causa de diminuição em favor do réu Jonathan.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

Tráfico de Drogas

Materialidade

A materialidade foi comprovada, conforme os seguintes elementos probatórios: (i) auto de apreensão das drogas (fls. 38-40); (ii) laudo pericial de constatação (fls. 41-43); (iii) laudos dos exames químico-toxicológico (fls. 130-149).

Tais documentos descrevem o material apreendido por métodos apropriados e conclui,

ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem na lista F1 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga guardada à traficância restou provada, com absoluta clareza da quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, manifestamente incompatíveis com a posse para consumo pessoal, conforme os parâmetros do art. 28, §2º, da Lei 11.343, de 2006.

Autoria

-Réu Johnatan

A autoria em relação ao réu Johnatan é certa, uma vez que a prova careada aos autos demonstra, de maneira cabal, que o réu guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, os entorpecentes descritos na denúncia.

Primeiro, o réu foi preso em flagrante delito, na posse dos entorpecentes, conforme o auto de prisão em flagrante (fls. -2); o boletim de ocorrência (fl. 27-35).

Segundo, o réu, em seu interrogatório, confessou que estava guardando/tendo em depósito a droga. Disse que conhecia o "dono" dos entorpecentes há poucas semanas na praça, cujo apelido era "Cabelo". E jamais vendeu para qualquer usuário. Iria guardar a droga de um dia para o outro. Não recebeu qualquer valor pelo serviço.

Terceiro, a prova oral colhida em juízo também confirma a confissão do réu.

Nesse sentido, a testemunha Jeanderson, ouvido sob compromisso, narrou que recebeu uma informação de que havia maconha na residência do acusado Johnatan. No local, foi recebido pela ré Lígia, a qual franqueou acesso. Na residência, foram localizadas não apenas pés de maconha (no quintal), mas também, no quarto do casal, uma estufa improvisada, crack, cocaína, balanças de precisão e materiais plásticos comumente utilizados para a mercadeja espúria.

A testemunha Anderson, ouvida apenas em solo policial, confirmou o depoimento dado por seu colega

-Ré Lígia

Em relação à ré Lígia, contudo, não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que esta também guardava/tinha em depósito os entorpecentes.

O réu Johnatan foi categórico que todo o entorpecente apreendido era dele, e que a acusada não possui qualquer vinculação com o tráfico.

Também em seu interrogatório, a ré Lígia negou ser sua a droga.

E as testemunhas da acusação, igualmente, nada de concreto trouxeram no sentido de que a ré Lígia tivesse qualquer vinculação com os entorpecentes.

Portanto, não há qualquer elemento a indicar o liame subjetivo entre a ré e o entorpecente, sendo a absolvição dele de rigor.

Associação para o Tráfico (art. 35)

Para a comprovação da materialidade do crime de associação para o tráfico, é imprescindível demonstrar os seguintes elementos típicos: i) um ânimo associativo, ou seja, "ajuste prévio e um mínimo de organização", (STF. 1ª Turma. RHC 75.236/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence); ou seja, é necessário um "dolo de se associar com estabilidade e permanência" (Enunciado 11 da Jurisprudência em Teses n. 45 do STJ), denominado de *societas sceleris*. Somente tal estabilidade e permanência que permitem diferenciar a associação o tráfico do mero concurso de pessoas; e ii) com o objetivo de "preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas"; e

No caso, não há prova de mencionada estabilidade e permanência entre os réus. Não há qualquer evidência de uma divisão de tarefas, hierarquia, ou distribuição dos proveitos do tráfico entre eles.

Ademais, não há qualquer prova a vincular Lígia aos entorpecentes, de modo que a absolvição de ambos no delito de associação é mesmo de rigor.

Causa de Diminuição (art. 33, §4, da Lei 11.343/06)

Deve-se reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por satisfeitos os requisitos legais.

Primeiro, O réu Johnatan é primário e de bons antecedentes.

Segundo, não há elementos que demonstrem que o réu se dedique a atividades criminosas, não havendo qualquer inquérito ou ação penal em curso em face do réu

(vide STJ. 3a Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596)).

É fato que o réu comprovou se dedicar à atividade lícita, trabalhando em restaurante, conforme as testemunhas de defesa.

Nesse sentido, as testemunhas de defesa também relataram que não observavam qualquer movimentação ilícita na residência dos réus e que o réu de fato trabalhava em restaurante japonês.

Terceiro, não há indícios que o réu integre organização criminosa. Nesse sentido, percebe-se que a quantidade de droga apreendida não permite concluir, por si, a participação do réu em organização criminosa. Nesse sentido vale mencionar que “a quantidade de drogas não constitui isoladamente fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena” (STF, HC 138.138/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 29.11.2016, noticiado no Informativo 849).

Portanto, a acusação busca ver afastado o redutor unicamente na quantidade de droga apreendida, o que já foi rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, todos os demais elementos de investigação colhidos não apontam qualquer envolvimento do réu com organização criminosa.

Por outro lado, a quantidade e variedade de drogas serão, por outro lado, devidamente valoradas na 1ª fase da dosimetria da pena.

Logo, satisfeitos os requisitos, faz jus o réu ao redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Individualização da Pena

De rigor, assim, a condenação pelo crime de tráfico de drogas o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ao crime do art. 33, caput, da Lei 11/343/06, são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão, de cinco a quinze anos, e multa.

Para a dosimetria, parte-se, portanto, da pena mínima de 5 ano de reclusão e 500 dias multa (art. 49 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, à luz das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, observo que a droga apreendida está entre aquelas mais severamente lesivas à saúde pública (crack), de modo que sua “natureza” da droga leva a pena-base. Por fim, a quantidade de droga excede, em muito, à normalidade das apreensões nesta comarca. Trata-se de enorme quantidade de crack (cerca de 3 quilos), o que demonstra a necessidade maior severidade na punição. Nesse sentido, diante da quantidade de entorpecente, a qual seria capaz de lesar a saúde de milhares de pessoas, elevo a pena mínima em 1/3 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Observo que não há critérios matemáticos fixos para exasperar a pena base, de modo que um maior rigor se faz aqui necessário. Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 8 ano(s), 4 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, deve-se reconhecer a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante da confissão espontânea feita em audiência. Portanto, atenuo a pena e fixo a pena-provisória em 6 ano(s), 11 mês(es) e 10 dia(s) de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, deve-se aplicar a minorante do art. 33, §4, da Lei 11.343/06 no quantum máximo de diminuição de 2/3, uma vez que não há elementos nos autos aptos a justificar uma redução para aquém desse patamar.

Observo que a quantidade e natureza da droga devem ser valoradas, necessariamente de acordo com a jurisprudência do C. STJ, na 1ª fase da dosimetria nos termos do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), conforme feito supra.

Nesse sentido:

[...]NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER NECESSARIAMENTE OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. [...]

[...] No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de

entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base.

(STJ. HC 665.401/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/6/2021). 13 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 580.641/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Com tais considerações, fixo a pena definitiva ao acusado em 2 ano(s), 3 mês(es) e 23 dia(s) de reclusão.

Adotando o critério da proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo da pena de multa e os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em tela, fixo a pena de multa em 231 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário-mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime aberto.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a substituição da pena privativa de liberdade. Em face do montante da pena aplicado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.

A substituição da pena privativa de liberdade é mais benéfica e, por isso, prejudica a aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que o delito praticado não tem vítima específica.

Da detida análise dos autos e à luz do art. 316 do Código de Processo Penal, extrai-se que deve ser modificada a situação processual do(a) acusado(a). Isso porque, uma vez fixado o regime aberto, este se mostra incompatível com a manutenção da prisão processual.

Dispositivo

Por essas razões, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para:

i) CONDENAR o réu JOHNATAN SAMUEL APOSTOLICO. já qualificado, por infração ao 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 ano(s), 3 mês(es) e 23 dia(s) de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de pena de multa no valor de 231 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo; e

ii) ABSOLVER o réu JOHNATAN SAMUEL APOSTOLICO da imputação baseada no art. 35 da Lei 11.343/06 e a ré LIGIA APARECIDA ALMEIDA, já qualificada, das imputações baseadas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06, e o faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condene o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100

(cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro.
Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06

*

Itararé, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA